

第 68 問

甲は、殺人の前科があり、その名前が広く知れ渡ってしまっていたことから、実名では就職ができないと考え、「A」という偽名で就職活動をすることにした。

そこで、甲は、履歴書用紙の氏名欄に「A」、生年月日、現住所欄には、それぞれ虚偽の内容を記入した上で、自己の顔写真を貼付して、履歴書を作成し（以下「本件履歴書」という。）、これをB社に提出した。

その後、甲は、B社における採用面接に合格した。甲は、B社から給与を振り込むための「A」名義の銀行口座を聞かれたため、C銀行で「A」名義の口座を開設することにした。C銀行での口座開設には、本人確認のために、身分証明書の写しが必要であったため、甲は、自己の運転免許証（公安委員会発行）の氏名欄に「A」と印字された紙を置き、メンディングテープを貼付して固定したものを作成し、これを用いて、コピー機で写真コピーを作成した。その上で、C銀行の窓口で、写真コピーを提出し、「A」名義の口座を開設し、預金通帳の交付を受けた。

甲は、B社の経理部で勤務を始めたが、もっと手軽に金儲けができないかと考えるようになり、B社の顧客情報を、競業社であるD社に売却することを考えた。そこで、甲は、深夜に、B社の営業課に保管されている顧客情報が記載されている書類（以下「本件書類」という。）を持ち出し、B社の近くにあるコンビニエンスストアに設置されているコピー機で、本件書類の写真コピーを作成し、本件書類を元の場所に戻した。なお、甲が本件書類を持ち出してから、元の場所に戻るまでの時間は、5分程度であった。

甲の罪責について、論じなさい（特別法違反の点を除く。）。

第1 甲が本件履歴書を作成し、B社に提出した行為

有印私文書偽造罪（159 I）の成否が問題となる（**論点** 「偽造」（155 I 等）の意義、**論点** 名義人の意義 **論** 司H24,旧H12-2,H15-2,H21-2、**論点** 資格（肩書）の冒用の場合における名義人の特定方法 **論** 予R2,旧H7-2）。ここでは、甲自身の顔写真を貼り付けている点が問題となるが、素材判例である最決平11.12.20は、「被告人の顔写真がはり付けられ、あるいは被告人が右各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、これらの文書に表示された名義人は、被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである。」と説示し、「偽造」に当たるとしている。

なお、本件履歴書は、経歴等の実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であるから、「事実証明に関する文書」に当たる（前掲最決平11.12.20もこのことを前提としている。）。

総合 270 頁 **論証** 138 頁
総合 270 頁 **論証** 138 頁
総合 271 頁 **論証** 139 頁

第2 甲が自己の運転免許証に「A」と印字された紙をメンディンググテープで貼付した上で、写真コピーを作成した行為

いわゆる写真コピーと偽造の問題である（**論点** 写真コピーと偽造 **論** 旧H12-2）。

この点について、判例（最判昭51.4.30【百選Ⅱ88】）は、「公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段としてもつ社会的機能を保護し、社会生活の安定を図ろうとするものであるから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれるものと解するのが相当である」。写真コピーは、「写ではあるが、複写した者の意識が介在する余地のない、機械的に正確な複写版であって、紙質等の点を除けば、その内容のみならず筆跡、形状にいたるまで、原本と全く同じく正確に再現されているという外観をもち、また、一般にそのようなものとして信頼されうような性質のもの、換言すれば、これを見る者をして、同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく、印章、署名を含む原本の内容についてまで、原本そのものに接した場合と同様に認識させる特質をもち、その作成者の意識内容でなく、原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうようなものであるから、このような写真コピーは、そこに複写されている原本が右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるものであり、それゆえに、公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いのである。右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、公文書偽造罪の客体たりうるものであって、この場合においては、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、また、右作成名義人の印章、署名の有無についても、写真コ

総合 275 頁 **論証** 144 頁

ピーの上に印章、署名が複写されている以上、これを写真コピーの保有する意識内容の場合と別異に解する理由はないから、原本作成名義人の印章、署名のある文書として公文書偽造罪の客体たりうるものと認めるのが相当である」(下線部は担当者)と述べており、あたかも原本と同一内容の文書を作成したものと捉え、有印公文書偽造罪(155I)の成立を認めている。

なお、その後、最決昭54.5.30、最決昭58.2.25、最決昭61.6.27が同様の判断を行っている。

第3 甲が「A」名義の口座を開設した行為

口座開設行為が詐欺罪(246I)を構成するかが問題となる(【論点】銀行取引と財産罪③～口座開設)ところ、預金通帳が「財物」に当たるか、他人名義の口座開設申込みが欺罔行為に当たるかについて論じる必要がある。

総合 249 頁 論証 125 頁

判例(最決平14.10.21)は、前者の点について「預金通帳は、それ自体として所有権の対象となり得るものであるにとどまらず、これを利用して預金の預入れ、払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有するものと認められるから、他人名義で預金口座を開設し、それに伴って銀行から交付される場合であっても、刑法246条1項の財物に当たると解するのが相当である。」と述べ、これを肯定している。

後者の点については、理論構成を明示していないものの、同決定はこれを肯定している。

第4 甲が本件書類を持ち出した行為

窃盗罪(235)の成否が問題となるところ、不法領得の意思の有無について検討する必要がある(【論点】不法領得の意思 論 司H27,H29,I旧H1-2,H19-2)。

総合 198 頁 論証 85 頁

不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」と定義される(最判昭26.7.13)ところ、本問では、一時利用目的である点において権利者排除意思が、情報から効用を得ている点において利用処分意思が問題となる。

なお、裁判例には、類似の事案について、窃盗罪の成立を肯定するものがある(東京地判昭59.6.15)。

答案構成

第1 甲が本件履歴書を作成し、B社に提出した行為

1 有印私文書偽造罪（159 I）の成否

↓

「事実証明に関する文書」「行使の目的」

↓

2 「偽造」とは、作成者と名義人の同一性を失わせることを指す

↓

あてはめ

↓

有印

↓

3 有印私文書偽造罪が成立する

↓

4 同行使罪も成立する

↓

5 詐欺利得罪（246 II）も成立する

第2 甲が自己の運転免許証に「A」と印字された紙をメンディングテープで貼付した上で、写真コピーを作成した行為

1 有印公文書偽造罪（155 I）の成否

↓

写真コピーも「文書」（公文書）に当たる

↓

「偽造」「印章」「署名」については、写真コピーの名義人は原本作成名義人であり、「印章」等も原本作成名義人のそれであるとして検討する

↓

あてはめ

↓

「行使の目的」

↓

2 有印公文書偽造罪及び同行使罪（158 I）成立

第3 甲が「A」名義の口座を開設した行為

1 詐欺罪（246 I）の成否

↓

預金通帳も「財物」に当たる

↓

2 「人を欺く」行為とは、財産的処分行為の基礎となるような重要な事項を偽る行為である

↓

あてはめ

↓

- 3 甲は「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、詐欺罪が成立する

第 4 甲が本件書類を持ち出した行為

- 1 窃盗罪（235）の成否

↓

客観的構成要件該当性及び故意（38 I）は問題なし

↓

不法領得の意思の有無

↓

- 2 ①権利者排除意思、②利用処分意思

↓

- 3 あてはめ

↓

- 4 甲には窃盗罪が成立する

第 5 罪数

甲には、①有印私文書偽造罪、②同行使罪、③詐欺利得罪、④有印公文書偽造罪、⑤同行使罪、⑥詐欺罪、⑦窃盗罪が成立する。①から③、④から⑥は、それぞれ牽連犯となる（54 I 後段）。これと⑦とは、併合罪となる（45前段）

第1 甲が本件履歴書を作成し、B社に提出した行為

1 この行為に、有印私文書偽造罪（159条1項）が成立しないか。

まず、本件履歴書は、経歴等の実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であるから、「事実証明に関する文書」に当たる。また、これをB社に提出することを前提として作成しているから「行使の目的」も認められる。

2(1) もっとも、本問では、甲自身の顔写真を貼付しており、その文書から生じる責任を免れようとする意思を有していないとも思われる。

そこで、「偽造」に当たるかが問題となる。

(2) 「偽造」とは、作成者と名義人の同一性を失わせることを指すところ、文書偽造罪の保護法益は、文書に対する一般人の信用であるから、名義人が誰であるかは、一般人において、誰の意思・観念が記載された文書であると認識するののかという観点から判断する。

確かに、本件履歴書には甲の顔写真が貼付されているが、継続的な雇用関係の基礎として氏名・経歴等は重要な意義を有し、履歴書は使用者に対してそれらを示すものであるため、本件履歴書の名義人は、履歴書記載の身上、経歴を有する殺人の前科がない「A」である。

一方で作成者は殺人の前科がある甲であるから、人格の同一性を失わせるものとして、「偽造」に当たる。そして、名義人であるAの「署名」が用いられているから有印である。

3 したがって、上記行為につき、有印私文書偽造罪が成立する。

4 また、B社に提出した行為に同行使罪（161条1項）が成立する。

1

5 さらに、甲は上記行為によりB社における社員たる地位を取得しているから、「人を欺いて」（246条1項）、「財産上不法の利益を得」たものとして、詐欺利得罪（同条2項）も成立する。

第2 甲が自己の運転免許証に「A」と印字された紙をメンディングテープで貼付した上で、写真コピーを作成した行為

1 この行為には、有印公文書偽造罪（155条1項）が成立しないか。

原則として「文書」は原本に限られるが、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有すると認められる限り「文書」に含まれると解する。写真コピーは、その複写の正確性から、そのような性格を有しており、「文書」に当たる。

そして、写真コピーは、その性質上、これを接する者をして印章・署名までを含めた原本の内容について、原本に接した場合と同様に意識させるものであるから、作成名義人は原本作成名義人であり、複写された「印章」「署名」も、原本作成名義人のそれである。

上記コピーの原本作成名義人は公安委員会であるから、上記コピーは名義人を公安委員会とする公文書であるところ、これを甲が作成しているから、作成者と名義人の同一性を失わせたものとして、「偽造」に当たる。また、公安委員会の「印章」「署名」も複写されているから、有印である。甲には「行使の目的」に欠けるところもない。

2 以上より、有印公文書偽造罪が成立し、これをC銀行に提出した行為に同行使罪（158条1項）が成立する。

第3 甲が「A」名義の口座を開設した行為

2

1 上記行為には、詐欺罪（246条1項）の成立可能性がある。

2 まず、預金通帳はそれ自体所有権の対象となるし、払戻しを受けられ
3 るなどの財産的価値を有し、「財物」に当たる。

4 2 では、甲が「A」であると偽った点が「人を欺く」行為に当たるか。

5 詐欺罪も財産罪である以上、詐欺罪としての処罰を正当化するような
6 法益侵害性が認められる必要がある。

7 そこで、「人を欺く」行為といえるためには、財産的処分行為の
8 基礎となるような重要な事項を偽る必要があると解する。

9 金融機関が本人確認を行うのは、犯罪利用防止目的などの公的目的の
10 みならず、その信用性維持という観点からも本人確認を行っているか
11 ら、名義人が誰かという点は経済取引上の重要事項である。

12 したがって、偽名の口座の開設は、財産的処分行為の基礎となるよう
13 な重要な事項を偽ったものとして、「人を欺く」行為に当たる。

14 3 そして、C銀行は、甲の欺罔行為によって、甲がAであると錯誤に陥
15 り、預金通帳を交付しているから、甲は「人を欺いて財物を交付させ
16 た」ものとして、詐欺罪が成立する。

第4 甲が本件書類を持ち出した行為

17 1 この行為には、「他人の財物を窃取した」ものとして窃盗罪（235
18 条）が成立することが考えられる。

19 客観的構成要件該当性及び故意（38条1項）については問題がない
20 が、甲には本件書類の返還意思があり、また、本件書類自体から効用を
21 得る意思がない以上、不法領得の意思が認められないのではないか。

3

2 領得罪の成立に際し、不法領得の意思の有無を判断する必要がある。

3 かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰な使用窃盗と窃盗罪との
4 区別、さらに、窃盗罪と毀棄罪との区別が困難になるからである。そし
5 て、その内容は、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として
6 （権利者排除意思）、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意
7 思（利用処分意思）であると解する。

8 3 本問では、上記のように一時使用目的しかないように思われるが、顧
9 客情報というB社の機密書類のコピーを作成し、競業社であるD社に交
10 付する意思で持ち出しているため、価値の消耗を伴う利用態様であっ
11 て、社会通念上許容されるものではない。そのような利用可能性の阻害
12 の認識はある以上、①権利者排除意思に欠けるところはない。

13 また、甲は、確かに機密資料それ自体から効用を得ているわけではな
14 く、機密資料上の顧客情報から効用を得ているのであるが、機密資料の
15 媒体としての価値は著しく低く、情報がそこに化体されていることに価
16 値が見出されているのだから、機密資料そのものから効用を得ている場
17 合同視することができ、②利用処分意思も認められる。

18 4 よって、甲には窃盗罪が成立する。

第5 罪数

19 甲には、①有印私文書偽造罪、②同行使罪、③詐欺利得罪、④有印公
20 文書偽造罪、⑤同行使罪、⑥詐欺罪、⑦窃盗罪が成立する。①から③、
21 ④から⑥は、目的手段の関係にあるため、それぞれ牽連犯となる（54
22 条1項後段）。これと⑦とは、併合罪となる（45条前段）。以上

4